



Roj: **STS 1908/1999 - ECLI:ES:TS:1999:1908**

Id Cendoj: **28079110011999102102**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **18/03/1999**

Nº de Recurso: **2485/1994**

Nº de Resolución: **224/1999**

Procedimiento: **RECURSO DE CASACIÓN**

Ponente: **PEDRO GONZALEZ POVEDA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Jaén, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Martos, sobre reclamación de cantidad; cuyo recurso fue interpuesto por D. Humberto , representado por el Procurador D. José Luis Pinto Marabotto, siendo parte recurrida SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CONSTRUCTORA GAMYCOL, representada por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Martín Jaureguibeitia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

1.- El Procurador de los Tribunales D. Manuel Rodríguez Calle, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Andaluza Constructora GAMYCOL, formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia de Martos, sobre reclamación de cantidad; contra D. Humberto , en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que "estimando íntegramente la demanda se condene a D. Humberto a abonar a la Sociedad Cooperativa Andaluza Constructora Gamycol de Torredonjimeno la cantidad de OCHO MILLONES CUATROCIENTAS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA PESETAS (8.442.940 pts.) más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y así mismo al pago de las costas".

2.- Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, se personó en autos el Procurador D. José Manuel Motilla Ortega, en nombre y representación de D. Humberto , quien contestó a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictara sentencia por la que "se desestimen todos los pedimentos de la demanda con imposición de costas a la parte actora".

3.- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, la Ilma. Sra. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia de Martos, dictó sentencia en fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro cuyo FALLO es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda presentada por la Sociedad Cooperativa Andaluza Constructor Gamycol, contra don Humberto , debo condenar y condeno a este último a que abone a la actora la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTAS VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA PESETAS, incrementada en los intereses legales correspondiente. Las costas serán a cargo de la parte vencida en este juicio".

4.- Por la representación de la actora se solicitó aclaración de la sentencia anteriormente mencionada, dictándose auto de aclaración por el Juzgado de Primera Instancia de Martos, en fecha 10 de febrero de 1994, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "S.Sª ACUERDA: Aclarar y rectificar de oficio parcialmente, el fallo de la sentencia que queda como sigue: "Que estimando parcialmente la demanda presentada por la

Sociedad Cooperativa Andaluza de Construcción GAMYCOL, contra D. Humberto , debo condenar y condeno a este último a que abone a la actora la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTAS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA PTS (8.426.130 pts), incrementada en los intereses legales correspondientes y del siguiente modo: Respecto a la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTAS VEINTIDOS PTS (7.438.522 pts), se liquidaron desde la fecha de interposición de la demanda y respecto a NOVECIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS DOCE PTS (987.612 pts) se hará desde la sentencia, por ser cantidad ilíquida hasta su momento. Así mismo, no se hace expresa condena en costas, respecto a las causadas en esta instancia".

SEGUNDO.-

Interpuestos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia por la representación procesal de ambas partes litigantes, y tramitado el recurso con arreglo a derecho la Audiencia Provincial de Jaén dictó sentencia en fecha 18 de julio de 1994, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando en parte los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por la actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Martos, con fecha 7 de Febrero de 1994, y auto de aclaración de fecha 10 de febrero de 1994, dictamos en los autos nº 82/91, debemos de revocar y revocamos dicha sentencia, y auto que se declara nulo, en parte, en el sentido de estimar parcialmente la demanda interpuesta por la representación de la Sociedad Cooperativa Andaluza Constructora Gamycol, contra D. Humberto , condenando a este a que abone a aquella, la cantidad de 7.907.961 pts, y los intereses establecidos en el art. 921 de la L.E.C., desde la fecha de la sentencia, absolviéndole de las restantes pretensiones y sin hacer expresa imposición de las costas del procedimiento, así como tampoco de las de esta alzada".

TERCERO.-

1.- El Procurador de los Tribunales D. José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de D. Humberto , interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Jaén, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en el nº 3 del artículo 1692 de la LEC, por infracción de los artículos 9.3 y 14.1 de la C.E. Por infracción del artículo 238.3 de la LOPJ en relación al art. 702 punto 2º . Por infracción del artículo 238.1 de la L.O.P.J. en relación al art. 55 de la L.E.C. y por infracción del art. 1715.2 L.E.C., en relación a las sentencias del T.S. de 4-6-93, Rep. Araz. 4477 y de 7-4-93, Rep. Araz 2796. SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en el nº 3 del artículo 1692 de la L.E.C. , por las mismas infracciones alegadas en el motivo anterior. TERCERO.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de LEC Se alega infracción por no aplicación de las reglas de valoración probatoria, establecidas en los arts. 1243 del C.C. en relación con el art. 610 de la Ley Procesal, regulador del valor de la prueba de Peritos. Se alega infracción de las reglas de valoración probatoria establecidas en el art. 1225 del C.C. respecto de los documentos privados. Infracción del art. 1253 del C.C. sobre presunciones, e infracción del art. 1214 del mismo cuerpo legal sobre la doctrina del onus probandi. CUARTO.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la LEC. Se alega infracción por no aplicación de las reglas de valoración probatoria establecidas en los arts. 1243 del C.C. en relación con el art. 610 de la Ley Procesal regulador del valor de la prueba de Peritos. Infracción de las reglas de valoración probatoria, establecidas en los artículos 1218 a 1224 del C.C. atinentes a los documentos públicos. Infracción del artículo 1253 del C.C. sobre las presunciones. Infracción del artículo 1214 del mismo cuerpo legal sobre la doctrina del onus probandi. QUINTO.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de LEC. Se alega infracción del artículo 1101 del C.C."

2.- Admitido el recurso de casación por auto de fecha 3 de octubre de 1995, se entregó copia del escrito a la representación de la recurrida conforme a lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la LEC, para que en el plazo de 20 días, puedan impugnarlo.

3.- El Procurador de los Tribunales D. José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Andaluza Constructora Gamycol, presentó escrito impugnando el recurso de casación interpuesto de contrario.

4.- Al no haberse solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día tres de marzo del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Estimada parcialmente la demanda sobre reclamación de cantidad, la parte debida del precio del contrato de obras concertado entre la sociedad demandante, como contratista, y el dueño de la obra demandado por éste se ha interpuesto recurso de casación, cuyo primer motivo se formula al amparo del ordinal 3º (aunque no se cita en cual de los dos incisos que el mismo contiene) del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando infracción de los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española; del artículo



238.3 de la Ley Orgánica del Poder en relación con el artículo 702 punto 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; del artículo 238.1 de la citada Ley Orgánica en relación con el artículo 55 de la Ley Procesal Civil y del artículo 1715.2 de esta misma Ley, en relación a las sentencias de este Tribunal de 4 de junio de 1993 y 7 de abril del mismo año. Se pretende en el motivo que, denunciado ante la Sala "a quo" el vicio de incongruencia de que adolecía la sentencia de primera instancia y estimado por la Sala que el Juzgador de la primera instancia había omitido pronunciarse sobre determinadas excepciones opuestas por el demandado-apelante, procedía la declaración de nulidad de actuaciones, con reposición de las mismas al momento en que se cometió la infracción y su devolución al Juzgado para que se dictase nueva sentencia.

El motivo, a cuya admisión se opuso el Ministerio Fiscal en el preceptivo trámite, carece de todo fundamento jurídico, no obstante el elenco de preceptos que se citan como vulnerados. La estimación de la concurrencia del defecto de incongruencia en la resolución combatida, ya sea por el Tribunal de apelación o por este de casación, al conocer de los pertinentes recursos, no determina la nulidad de la sentencia incongruente sino su revocación o casación, con la obligación del Tribunal "ad quem" de dictar nueva sentencia supliendo los defectos determinantes de la incongruencia (véase, en relación con la casación, el artículo 1715.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil); procede, en consecuencia, la desestimación del motivo.

Desestimación que igualmente recae sobre el motivo segundo, a cuya admisión se opuso asimismo el Ministerio Fiscal, y en el que por el mismo cauce procesal que el anterior se invocan como infringidos los mismos preceptos; en este motivo se vuelve a proponer la misma solución procesal que el anterior al haber apreciado el Tribunal de apelación la nulidad del auto de aclaración de sentencia dictado por el Juzgado con infracción de lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del 363 de la Ley Procesal Civil; no se alcanza a comprender por esta Sala que finalidad tendría la reposición de las actuaciones ni cual sería la resolución que habría de dictar el Juzgador de Primera Instancia para corregir la infracción de los dos preceptos últimamente citados, una vez anulado el auto infractor.

Segundo.- El motivo tercero alega infracción del artículo 1243 del Código Civil en relación con el artículo 610 de la Ley Procesal; del artículo 1225 del Código Civil; del artículo 1253 y del 1214 del mismo Código, Aparte de la incorrecta cita en un mismo motivo de casación de preceptos heterogéneos como son los relativos a la valoración de los distintos medios probatorios que cita así como al regulador de la carga de la prueba, tal cita conjunta pone de manifiesto, así como el desarrollo del motivo, que lo pretendido es que por esta Sala se proceda, como si de un órgano judicial de instancia se tratase, a revisar el material probatorio aportado a los autos haciendo una nueva valoración conjunta de todos ellos, incluso haciendo uso de la prueba de presunciones, acorde con el particular criterio del recurrente; no siendo esa la función de esta Sala, ha de rechazarse el motivo al igual que ha de serlo el cuarto en el que, con la misma pretensión de que por esta Sala se proceda a un examen conjunto de la prueba, se denuncia infracción del artículo 1243 del Código Civil en relación al artículo 610 de la Ley Procesal; de los artículos 1218 a 1224 del Código Civil y de los artículos 1253 y 1214 del mismo Cuerpo legal.

Tercero.- Por el cauce procesal del ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega, en el motivo quinto, infracción del artículo 1101 del Código Civil "en relación con el daño moral establecido por la jurisprudencia el T.S. en sus sentencias de 3-6-91 y 20-7-88".

Tiene declarado esta Sala que para que pueda tenerse por formulada reconvención, aunque sea en la llamada forma "implícita", es necesario que en el suplico del escrito de contestación a la demanda se formule expresamente cualquier petición que exceda de la pura y simple absolución de las peticiones de la demanda (sentencias de 14 de octubre de 1991, 9 de diciembre de 1993, 19 de noviembre de 1994 y 8 de noviembre de 1996). En aplicación de esta doctrina, esta Sala no puede aceptar la aplicación que hace el Tribunal "a quo" de la doctrina contenida en las sentencias que cita de 7 de marzo de 1988 y 6 de febrero de 1985 entendiéndolo que, en el caso, se dio una reconvención implícita (si bien, aunque apreció esa reconvención no obró en consecuencia, declarando nulidad de actuaciones para que se diese traslado al actor-reconvenido, sino que entró a examinar directamente esas pretendidas pretensiones reconvencionales). El demandado-recurrente en casación formuló el suplico de su escrito de contestación a la demanda en los siguientes términos: "se dicte sentencia por la que se desestimen todos los pedimentos de la demanda con imposición de costas a la parte actora"; como se ve tal suplico no contiene petición expresa alguna en relación con la indemnización de daños y perjuicios por la demora del actor en la entrega de la obra y que fue reconocida a favor del demandado, pronunciamiento firme al no recurrir en casación el actor gravado, ni sobre la indemnización de daños morales que pretende el recurrente, sobre lo que no debía pronunciarse la Sala de instancia, y que este Tribunal no puede entrar a examinar por razón del principio de congruencia al no existir petición expresa en el suplico de la contestación a la demanda, lo que, aparte de no resultar acreditados tales daños morales, hace decaer el motivo.

Cuarto.- La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso determina la de éste en su integridad con la preceptiva condena en costas de la parte recurrente, de acuerdo con el artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Humberto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Jaén de fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Pedro González Poveda.- Antonio Gullón Ballesteros.- firmados y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.